

1500082-69.2022.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

1500082-69.2022.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500082-69.2022.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE SANTANA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra GEOVANA CAROLINA RODRIGUES SANTANA e LUIZ HENRIQUE SANTANA, devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes as condutas tipificadas no artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Narra a inicial acusatória que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta de 09h45, na residência localizada na Rua Noruega, n.º 23, Centro, nesta cidade e comarca de Itápolis, os denunciados GEOVANA CAROLINA RODRIGUES SANTANA e LUIZ HENRIQUE SANTANA se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas, razão pela qual guardavam e mantinham em depósito, para venda clandestina: 1,34 gramas da droga "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em um invólucro plástico; e 35,1 gramas da droga cocaína, acondicionada em um invólucro plástico, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica (vide autos de constatação de natureza de substância entorpecente provisório de fls. 21 e 22 e laudos periciais de fls. 117 e 120), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (fls. 131/132). Os réus foram devidamente notificados, apresentando resposta escrita às fls. 164/165.

Denúncia recebida em 28 de junho de 2022, conforme decisão de fl. 166/173. Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, em seguida, interrogado o acusado. Após, o(a) representante do Ministério Público e o(a) defensor(a) apresentaram alegações finais orais.

Os autos me vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve parcial êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, “Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)” (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No caso do delito de tráfico de drogas, são indícios suficientes para a condenação do(a) agente, dentre outros: a) a confissão da prática do crime; b) a apreensão de substância entorpecente em poder do(a) autor(a) do fato e/ou de dinheiro em espécie (normalmente fracionado em notas miúdas, não possuindo o(a) denunciado(a) explicação convincente para a origem do numerário), bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes; e) a circunstância de o(a) acusado(a) ser conhecido no meio policial como traficante de drogas, responder a inquérito, já ter sido ou estar sendo processado, e/ou possuir condenação pela prática do referido delito. Em tais casos, ainda que o(a) autor(a) do fato não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, esses indícios (prova indireta) permitem que o magistrado conclua, em processo indutivo, ser ele(ela) traficante de drogas.

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 13/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/20), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fls. 21/22), pelas imagens fotográficas (fls. 23/26), pelo laudo toxicológico definitivo (fs. 112/116, 117/119 e 120/122) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa em relação ao crime de tráfico de drogas para o acusado LUIZ HENRIQUE SANTANA.

Com efeito, restou demonstrado que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta de 09h45, na residência localizada na Rua Noruega, 23, Centro, nesta cidade e comarca de Itápolis, o denunciado LUIZ HENRIQUE SANTANA guardava e mantinha em depósito, para venda clandestina: 1,34 gramas de maconha, acondicionada em um invólucro plástico; e 35,1 gramas de cocaína, acondicionada em um invólucro plástico, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

No dia 28 de janeiro de 2022, policiais civis em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.º 1500030-46.2022.8.26.0274, se deslocaram até o endereço residencial do denunciado. No local, encontraram GEOVANA na sala e LUIZ no banheiro. Na ocasião, LUIZ HENRIQUE percebeu a presença dos policiais na moradia e imediatamente dispensou na pia do banheiro certa quantidade de cocaína. Contudo, o saco plástico que continha a droga foi apreendido e, através de laudo pericial, confirmou-se a presença de cocaína.

Em buscas pela residência, os policiais lograram êxito em apreender, no quarto, dentro do colchão, no guarda-roupas e em outros locais da casa, a quantia de R\$ 5.283,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e três reais), proveniente da venda de drogas.

Na sala da casa, no painel de madeira que sustenta o televisor, dentro de um copo de plástico, os policiais encontraram duas porções de cocaína, ainda em pedra, de tamanho médio. E, em uma cadeira no quintal da casa, em frente à porta de entrada da moradia, foi localizada uma porção de maconha.

Ademais, foram apreendidos no local diversos sacos plásticos comumente utilizados para acondicionamento e venda de cocaína, além de prato com resquícios de drogas e balança de precisão.

Ao ser indagado a respeito das drogas e do dinheiro, LUIZ confirmou que as drogas eram de sua propriedade e que o dinheiro era proveniente da venda do entorpecente. Vejamos.

O acusado LUIZ HENRIQUE SANTANA, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que “assume a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como dos objetos destinados a embalagem e pesagem, afirmando que o entorpecente era destinado a venda; Em relação ao dinheiro apreendido, relata que é decorrente da venda de seu veículo VW/Gol; Em relação a pessoa de GEOVANA CAROLINA, afirma que há um tempo manteve um relacionamento amoroso com ela, porém atualmente estão separados, esclarecendo que ela estava na residência do interrogando, vez que estava tentando reatar o romance; Que afirma que GEOVANA não tem relação nenhuma com o entorpecente, objetos e dinheiro apreendido, nesta data, em sua residência; Deseja constar que a causa da separação com GEOVANA se deu, pois ela descobriu que o interrogando estaria traficando drogas, sendo que ela não aceitava tal condição, vez que, em outra ocasião, ela já havia sido presa em decorrência de tráfico de drogas, portanto não queria mais se envolver com este tipo de situação” (sic) (fl. 07 - grifo meu).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado LUIZ HENRIQUE SANTANA confessou a autoria delitiva. Sustentou que as drogas, o dinheiro, os sacos plásticos e a balança de precisão são de sua propriedade. Afirmou que apenas o interrogado reside no local dos fatos, sendo que a corré reside com os pais dela. No dia anterior havia discutido com a corré e levou consigo, para a sua residência, o celular dela. Na data dos fatos, a corré esteve em sua casa para levar o celular dela, ocasião em que os policiais civis chegaram à residência e apreenderam as drogas. Reafirma que a ré não residia com o acusado no local dos fatos. O dinheiro apreendido é produto da venda de um veículo VW/Gol. O interrogado vendeu o veículo

por R\$ 6.500,00 e iria investir os R\$ 1.500,00 em drogas. Havia 35g de cocaína no momento em que os policiais ingressaram, sendo que o interrogado já havia vendido 15g do estupefaciente. Havia voltado a vender drogas há 2 ou 3 meses. A acusada GEOVANA CAROLINA RODRIGUES SANTANA, ao ser interrogada na fase policial, sustentou que "a residência, local dos fatos, pertence a LUIZ HENRIQUE SANTANA e não tem envolvimento algum com o que foi apreendido na residência dele, esclarecendo que reside com sua mãe e irmãos na Rua Américo Ap. Nanetti, 53, Jd. Silveira, Itápolis/SP; Esclarece que estava na residência, vez que estão tentando reatar o romance, ressaltando que o fim do namoro seu deu, pois descobriu que LUIZ estava envolvido com drogas, e a interrogada, por já ter sido presa em outra ocasião em posse de 2 porções de maconha, não queria mais se envolver neste tipo de situação" (sic) (fl. 10 - grifo meu).

Na audiência de instrução e julgamento, a denunciada GEOVANA CAROLINA RODRIGUES SANTANA negou a autoria delitiva. O corréu LUIZ HENRIQUE assumiu a propriedade das drogas, dos sacos, da balança e do dinheiro. Teve um relacionamento com o réu, mas estavam separados há 3 meses, pois LUIZ HENRIQUE queria se mudar para o Jardim Esperança e voltar a mexer com drogas. A interrogada estava morando com sua mãe no bairro Jardim Silveira. No dia anterior, LUIZ havia estado na casa de sua genitora e levado consigo o celular da depoente. No dia dos fatos, a interrogada foi até a casa dele para pegar o celular. O corréu estava no banheiro quando os policiais entraram. Nada de ilícito foi encontrado com a ré. Não sabe se o réu morava com mais alguém no local. Viu que os policiais encontraram as drogas. O acusado tinha um VW/Gol, "quadrado", da cor azul. Na época dos fatos ele não estava mais com esse carro.

As testemunhas EDUARDO JÚLIO PEREIRA FILHO e DOUGLAS CARDELLI, policiais civis, em solo policial, disseram que "estavam investigando ocorrência de tráfico de drogas, e investigavam a participação de LUIZ HENRIQUE SANTANA e sua companheira GEOVANA, os quais residem na Rua Noruega 23- Fundos, Vila Jd. Esperança. Que, aquele local é conhecido por ser frequentado por traficantes e usuários, sendo que inúmeros flagrantes de tráfico de drogas foram feitos naquela Vila. Por esse motivo, não há possibilidade de realizar campanhas e, também as investigações indicaram que o casal alvo havia instalado uma câmera, para monitorar a entrada do corredor que leva à casa. As investigações evoluíram, com fortes indícios da traficância por parte dos então investigados, sendo que foi possível apurar que o tráfico ocorria na residência do casal. Que foi redigido relatório e, pelo delegado, encaminhado representação judicial para concessão de ordem de busca domiciliar, o que foi concedido. Na manhã de hoje, juntamente com outros policiais civis e dos delegados desta Unidade, a busca foi feita. Logo na entrada, o depoente viu a câmera instalada na parede da casa dos fundos, ou seja, do casal, e, quando entrou na casa, viu que LUIZ estava no banheiro, com a torneira da pia aberta, se desfazendo de drogas. Que, não conseguiu impedir que ele jogasse toda a droga na pia, deixando os plásticos que a droga estava envolta, os quais foram apreendidos. Naquele banheiro, em meio as roupas sujas, foi apreendido um prato com resquício de drogas. No quarto do casal, estava GIOVANA. Que foi dada ciência da ordem judicial e as buscas foram iniciadas. Na sala, foi localizada duas porções de cocaína, ainda em pedra, de tamanho médio. No quarto do casal foi apreendido a importância de cinco mil, duzentos e oitenta e três reais, em cédulas de valores diversos, montante este que estava escondido em vários locais do quarto, incluindo embaixo do colchão. Foram apreendidos os dois celulares do casal; saquetes plásticos e do tipo ziplock; caderno de anotações; uma balança de precisão, porém esta foi quebrada por LUIZ, logo após ele jogar a droga; uma porção de maconha, está na área de fora da casa e a câmera que monitorava a entrada da casa. Diante dos fatos, deu voz de prisão ao casal e apresentou-os nesta Unidade" (sic) (fls. 04/05 e 06 - grifo meu). Ao ser inquirida na audiência de instrução e julgamento, a testemunha EDUARDO JÚLIO PEREIRA FILHO esclareceu que estavam investigando o tráfico de drogas no bairro Jardim Esperança, conhecido como Vila. Asseverou que a casa situada à Rua Noruega, n.º 23, era bastante frequentada por viciados e traficantes. Não foi possível fazer campanha no local, pois havia uma câmera que filmava todos que entravam e saíam da residência. Durante o cumprimento do mandado de busca, perceberam que o réu estava

no banheiro com a torneira da pia aberta jogando droga no ralo da pia. A corré estava no quarto da residência. Foram localizados vários sacos de geladinho e do tipo Ziplock para embalar drogas. Encontraram maconha e cocaína, bem como R\$ 5.000,00 em espécie. A denúncia não mencionava o nome dos réus, apenas o endereço. Tampouco mencionava se o tráfico era perpetrado por um casal. Tomaram conhecimento da existência da câmara antes de darem cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Havia um portão de ferro e um muro dos dois lados. A câmara filmava o corredor da referida residência. Os réus já foram abordados várias vezes com drogas. Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais. Além disso, é fato notório e de conhecimento geral que, nos crimes (e atos infracionais) de tráfico de drogas, impera a lei do silêncio, haja vista que a(s) testemunha(s) do fato, sentindo-se amedrontada(s) e temendo por sua integridade física e/ou de seus amigos e familiares, optam por se calar, por fornecer pouco(s) detalhe(s) a respeito da empreitada criminosa ou, simplesmente, por mentir à autoridade policial e/ou ao(à) magistrado(a). Em tal contexto, a(s) denúncia(s) anônima(s) e o(s) depoimento(s) de policiais civis e militares possuem grande valor probatório.

5. A autoria do crime de associação para o tráfico não restou demonstrada em relação aos acusados.

O delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006 resta caracterizado quando duas ou mais pessoas se associarem (reunirem-se, juntarem-se) com a finalidade de praticarem (realizarem, cometerem) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1º, e 34 da Lei 11.343/2006.

Como bem esclarece Guilherme de Souza Nucci, cuida-se da “associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes”. De acordo com o referido autor, “a associação criminosa há de ser estável e permanente. Do contrário, seria somente um concurso de pessoas” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 411 – grifo meu). Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, conclui-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para prática do crime pretendido. [...]” (HC 124.164, 2ª T., rel. Teori Zavascki, j. 11.11.2014 – grifo meu).

Esse é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. II – De outro lado, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006” (REsp 1.113.728/SC, 5ª T. rel. Felix Fischer, 29.09.2009 – grifo meu).

Como esclarece Guilherme de Souza Nucci, “a advertência feita no tipo penal (reiteradamente ou não) quer apenas significar que não há necessidade de haver habitualidade, ou seja, não se demanda o cometimento reiterado das figuras típicas descritas nos arts. 33 e 34, bastando a associação com o fim de cometê-los” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 414 – grifo meu).

No caso dos autos, não restou demonstrado que os réus se associaram, de forma

estável e permanente, para o fim de praticarem reiteradamente ou não as condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, entre elas a de guardar e manter em depósito drogas para o consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Com efeito, os elementos de prova colhidos ao longo da instrução probatória não demonstraram o vínculo de estabilidade entre os acusados, mas, tão somente, que o réu LUIZ HENRIQUE SANTANA, no dia dos fatos, estaria guardando e mantendo em depósito 1,34g de maconha e 35,1g de cocaína para venda clandestina, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Assim, de rigor a absolvição dos acusados do crime do artigo 35 da Lei de Drogas.

6. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do(s) acusado(s) LUIZ HENRIQUE SANTANA pela prática do delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado na inicial acusatória.

7. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

In casu, embora primário e portador de bons antecedentes o acusado se dedica à prática de atividades criminosas, porquanto, antes de atingir a maioridade, envolveu-se com a prática de atos infracionais, o que demonstra seu envolvimento prolongado com o mundo do crime (conforme certidão de fl. 53).

Conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, “A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes” (AgRg no REsp 1560667/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017 – grifo meu). No mesmo sentido: HC 364.837/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017; AgRg no REsp 1653501/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017; HC 299.673/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016.

Ademais, foram apreendidos no local dos fatos petrechos relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes (balança de precisão, caderno de anotações, 93 sacos do tipo “geladinho”, 13 sacos plásticos do tipo “Ziplock” para embalar drogas), R\$ 5.283,00 em espécie, não tendo o réu comprovado a procedência lícita do referido numerário (suposta venda de um veículo VW/Gol) e uma câmera de segurança wifi para monitorar a aproximação de policiais.

Oportuno ainda destacar que, de acordo com os policiais civis, era intensa a movimentação de usuários e traficantes na residência do réu.

Finalmente, o acusado confessou em seu depoimento que já estava traficando há 2 ou 3 meses.

II.3 – Da dosimetria das penas

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância

judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

No caso dos autos, nenhuma das 8 (oito) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima) pode ser valorada negativamente.

Estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Reconheço as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, atentando para o disposto no enunciado da Súmula n.º 231 do STJ.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. “Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 – grifo meu).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena

definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, com fundamento nos artigos 33, §§ 2º, "b", e 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o acusado já foi contemplado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, prevalece no STF e no STJ o entendimento de que o sursis é inaplicável aos crimes hediondos ou equiparados, pois a dimensão do benefício não se coaduna com a natureza do delito, em relação ao qual a própria CF, em seu artigo 5º, XLIII, determinou tratamento mais severo (STF, HC 101.919/MG; STJ, HC 197.268/SP).

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

a) absolver a acusada GEOVANA CAROLINA RODRIGUES SANTANA da imputação relativa aos crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

b) absolver o acusado LUIZ HENRIQUE SANTANA da imputação relativa ao crime do artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Concedo à ré GEOVANA CAROLINA RODRIGUES SANTANA o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não aportaram aos autos notícias de que a acusada tenha voltado a delinquir após os fatos objeto da presente ação penal. Ademais, não se acham presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Expeça-se o competente alvará de soltura, devendo a ré ser posta imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer presa.

3. Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado LUIZ HENRIQUE SANTANA e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, que continua necessária para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: "HABEAS CORPUS - Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal - [...] Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência - Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada [...]". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2262474-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020 - grifo meu).

4. Outras disposições

Condeno os acusados ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final.

Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir prejuízo material constatado.

Transitada em julgado a sentença:

Incluam-se o nome dos condenados no rol dos culpados.

Notifiquem-se os condenados para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88;

Porque não interessa a preservação das drogas apreendidas, oficie-se, determinando a incineração delas, mediante termo circunstanciado.

Demonstrado que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, decreto seu perdimento em favor da União Federal, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itapólis, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA